

1501103-48.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... perfeitamente recusar-se a praticar o tráfico.

No mérito, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico majorado pelo fato de ter sido cometido nas dependências de estabelecimentos prisionais foi provada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão da droga, boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e o laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501103-48.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501103-48.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2085492/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 4314773 - DEL.POL.S.VICENTE, 1197/2019 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2085492 - DEL.POL.S.VICENTE, 1197/19/217 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA DE LANA OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 9 (nove) laudas.

Vistos.

FERNANDA DE LANA OLIVEIRA e MARIA BEATRIZ DE SOUZA SILVA, qualificadas nos autos, estão sendo processadas como incursoas no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que, no dia 23 de março de 2019, por volta das 09h50, nas dependências da Penitenciária II, situada na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, Km 282, Humaitá - São Vicente/SP, traziam consigo, transportavam, ocultavam e guardavam porções de cocaína e maconha, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, as rés FERNANDA e MARIA BEATRIZ dirigiram-se à

Penitenciária II de São Vicente, na posse de drogas, para visitar os detentos Lucas Rafael Oliveira Almeida e Wagner Assunção Alves dos Reis, respectivamente, visando a entrega dos entorpecentes a terceiros no interior do estabelecimento prisional. Segundo descrito, durante o procedimento de fiscalização de visitas, inicialmente passou a ré FERNANDA, através da máquina de Raio X (Body Scanner), ocasião em que se detectou uma imagem estranha na região pélvica e, diante da negativa da ré sobre a posse de algo ilícito, repetiu-se o exame, que foi confirmado.

A acusada foi conduzida até uma sala reservada, onde retirou o objeto de sua vagina, constatando-se que se tratava de um invólucro plástico, contendo uma porção de cocaína, com cerca de 106g.

Conta, ainda, que, enquanto se aguardava a chegada da Polícia Militar, a ré MARIA BEATRIZ submeteu-se ao procedimento regular de fiscalização, também sendo acusado pelo Body Scanner a existência desta vez de duas imagens estranhas na região pélvica desta vistorianda.

Questionada a respeito, a corré MARIA BEATRIZ, a princípio, negou a posse de algo ilícito. Novamente submetida a exame que confirmaram as imagens, a acusada acabou assumindo que ela mesma havia feito e introduzido drogas em seu ânus.

Em sala reservada, MARIA BEATRIZ retirou o saco plástico, verificando-se que se tratava de uma porção da droga maconha com cerca de 51g e uma porção de cocaína com cerca de 70g.

As rés foram presas em flagrante e no âmbito policial manifestaram o desejo de somente falar em juízo.

Auto de prisão em flagrante (fls. 1). Laudo de exibição e apreensão de fls. 15/17.

Auto de constatação preliminar (fls. 18/19). Fotografias às fls. 20/24. Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 41/42 e 43/42).

Denúncia apresentada às fls. 128/132.

Determinada a notificação das rés, para oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia (fls. 133/134).

Exame químico-toxicológico definitivo positivo (fls. 192/194).

A ré MARIA BEATRIZ apresentou defesa prévia às fls. 205/208.

A ré FERNANDA apresentou defesa prévia às fls. 210/216.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida às fls. 217/218.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 222/223), oportunidade em que foi ouvida uma testemunha, bem como, ao final, foram as rés interrogadas (fls. 275).

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 279/284, oportunidade em que pugnou pela procedência do pedido acusatório, reconhecendo-se, entretanto, a causa de diminuição de pena no patamar mínimo.

Após, manifestou-se a defesa da ré FERNANDA (fls. 290/300), requerendo a absolvição da ré quanto aos crimes descritos na denúncia, haja vista que foi coagida pelo seu companheiro, por ser usuário e viciado, a obrigou que ela levasse o referido entorpecente para o interior do estabelecimento prisional. Aduz que a ré não foi abordada traficando, estava sem dinheiro ou qualquer atitude que demonstrasse traficância.

Pugna pelo reconhecimento de crime impossível, visto que a tentativa de ingressar com droga em presídio é considerado meio absolutamente ineficaz, considerando que para entrar no estabelecimento prisional, a autora seria submetida à minuciosa inspeção. Sem prejuízo, requer o reconhecimento da ilegalidade da apreensão das drogas, porque a obtenção da prova teria afrontado a dignidade da pessoa humana. De modo subsidiário, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da penal disposta no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Por fim, após regular intimação (f. 301), manifestou-se a defesa da ré Maria Beatriz (fls. 304), reiterando a manifestação de fls. 264/265, oportunidade em que pugna pela absolvição da ré, e, de forma subsidiária, a sua condenação no mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, inviável o reconhecimento de nulidade da prova obtida, pois exame de raio X para detectar drogas escondidas em cavidades corporais não violam os princípios de proteção à dignidade da pessoa humana, notadamente porque o exame de raios X não é procedimento invasivo ou degradante.

Outrossim, não há de se falar em meio absolutamente ineficaz, uma vez que mesmo com a existência de aparelhos de detecção de objetos ilícitos nos estabelecimentos prisionais, é possível a entrada de drogas, sendo meio relativamente eficaz, não podendo se falar em crime impossível.

A prática de crime doloso não está garantida pelo princípio da dignidade humana, por evidente.

Nessa linha, havendo suspeita que o visitante do presídio esteja portando drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista íntima, que por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos ditames legais.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. [...]. 2. Arguição de nulidade da busca pessoal diante da realização de revista íntima. Afastamento. Configuração de fundadas razões para realização do procedimento de busca pessoal. Detecção, através de aparelho de body scanner, que a apelante possuía volume na região da cintura. Condução até ambiente reservado onde foi efetuada busca pessoal por agente penitenciária de mesmo gênero. Observância do art. 249 CPP. Localização de um invólucro contendo substância entorpecente na costura da veste íntima da apelante que não chegou a se despir e retirou o invólucro voluntariamente. Inexistência de aplicação de método invasivo ou vexatório durante a busca pessoal. Nulidade não caracterizada. Precedentes do STJ. [...] (TJSP ° 1500485-23.2020.8.26.0616 - Relator Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli - Julgado 29/03/2022)

Por fim, a coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade, prevista no artigo 22 do Código Penal, portanto, a alegação, pela Defesa, de sua incidência transfere-lhe o ônus de comprová-la, demonstrando que a ré sofreu ameaça grave a ponto de lhe impossibilitar a realização de conduta diversa daquela delituosa. Assim, para o reconhecimento da figura jurídica da coação moral irresistível, competia a quem a alega trazer aos autos provas irrefutáveis dessa situação, ônus do qual a parte não se desincumbiu, já que manifestou de forma vaga e sem amparo em prova segura.

Como se não bastasse, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que, no caso concreto, a ré poderia perfeitamente recusar-se a praticar o tráfico.

No mérito, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico majorado pelo fato de ter sido cometido nas dependências de estabelecimentos prisionais foi provada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão da droga, boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e o laudo de constatação provisória, confirmado em definitivo às fls. 192/194, além da prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão das rés.

A autoria é certa.

A forma de acondicionamento das drogas, tornam claro o dolo de traficância.

Os exames químico-toxicológicos deixaram certa a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

A agente de segurança penitenciária, Juliana Peres dos Santos Silva, ouvida em Juízo na condição de testemunha, confirmou que as rés foram visitar os respectivos companheiros e ao passarem no procedimento de scanner uma passou identificando imagem suspeita e foi levada em local reservado fazendo a retirada das drogas. Interrogada em Juízo, a ré MARIA BEATRIZ confessou a prática delitiva, afirmando que foi até a penitenciária para visitar o marido quando passou pelo scanner, e

diante da suspeita, passou de novo, sendo vista a imagem. A funcionária perguntou se ela tinha algo e disse que sim, e foi para sala reservada com agente penitenciária Vânia e Juliana, tendo a declarante retirado os itens que trazia consigo. Alegou que eram 26g de maconha e acha que umas 30g de cocaína. Sustentou que o esposo não sabia, foi a primeira vez e, não sabe o que deu na sua mente aquele dia.

A corré FERNANDA, também confessou a prática criminosa, confirmando que entrou na penitenciária com droga, e que, após passar pelo raio X, levaram-na para uma sala, obrigaram a retirar de suas partes íntimas. Ficou esperando em um quartinho e foram levadas para uma Delegacia. Afirmou que iria entregar a droga para o companheiro. Disse ter sido a primeira vez que entrou no presídio portando drogas.

Pois bem.

Corroborados com a confissão das rés, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas majorado. Vale ressaltar que os relatos da agente de segurança penitenciária envolvidas na prisão das acusadas, nas duas fases da persecução penal, são firmes e coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos.

Por ser crime de perigo abstrato, pune-se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente.

No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.

Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destaco que o delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização.

Nesse sentido:

TRÁFICO PRIVILEGIADO MAJORADO. Apelante que foi presa em flagrante com 78,4g de maconha escondidos na cavidade vaginal enquanto tentava ingressar como visitante em unidade prisional. Apelo defensivo buscando o reconhecimento de que se tratava de crime impossível. Inocorrência. Tipo misto alternativo. Tráfico já configurado com o recebimento, ocultação e transporte. Precedentes. Coação moral irresistível não demonstrada e sequer alegada pela própria apelante. Condenação mantida.

Entendimento da súmula 231 do C. STJ que foi corretamente aplicado. Redutor que poderia ter pesado na fração máxima. Majorante bem aplicada. Penas reduzidas a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com 221dias-multa. Possibilidade de substituição por restritivas de direitos e regime inicial aberto. (TJSP 500489-73.2018.8.26.0311 – Relator Des. Otávio de Almeida Toledo – Julgado 28/01/2020)

Além disso, a majorante de ter sido o fato praticado - foi devidamente comprovado, notadamente porque o STJ pacificou entendimento de que sequer é necessário que a droga passe para a ala dos detentos, bastando que o cometimento dos crimes tenha ocorrido em seu interior, para que incida a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA. MAJORANTE. TRÁFICO PRATICADO EM PRESÍDIO. AUTORES SUBMETIDOS A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

ORGANIZAÇÃO DOS CRIMES POR MEIO DE TELEFONES. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

3. O inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06 não faz a exigência de que as drogas, objeto do crime, efetivamente passem por dentro dos locais que se busca dar

maior proteção, mas apenas que cometimento dos crimes tenha ocorrido em seu interior. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reformular a pena aplicada a um dos pacientes. (HC 440.888/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Assim, no meu entender, a prática do tráfico de drogas majorado está provada de modo cabal.

Passo a dosar a pena:

Ré Fernanda De Lana Oliveira

Na primeira fase (circunstâncias judiciais), em decorrência da alta nocividade da droga cocaína no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, constato ter a ré confessado espontaneamente a autoria do crime, motivo pelo qual reconheço a atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, razão pela qual retorna a pena ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na derradeira fase, em decorrência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, majoro a pena anteriormente fixada em mais 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na derradeira fase, por se tratar de ré primária, sem maus antecedentes, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização dessa natureza cabe a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Reputo, portanto, adequada a concessão da benesse; em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), quantum justificado pela pouca variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, perfazendo a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, fixo as penas da ré FERNANDA, em definitivo, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso legal.

Ré Maria Beatriz De Souza Silva

Na primeira fase, em decorrência da alta nocividade da droga cocaína no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, constato ter a ré confessado espontaneamente a autoria do crime, motivo pelo qual reconheço a atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal, razão pela qual retorna a pena ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na derradeira fase, em decorrência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, majoro a pena anteriormente fixada em mais 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na derradeira fase, por se tratar de ré primária, sem maus antecedentes, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização dessa natureza cabe a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Reputo, portanto, adequada a concessão da benesse; em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), quantum justificado pela pouca variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, perfazendo a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, fixo as penas da ré MARIA BEATRIZ, em definitivo, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso legal.

Diante da quantidade de pena corporal aplicada, assim como a primariedade, a

ausência de maus antecedente e a pouca quantidade de droga apreendida, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena.
O tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo, segundo disposto no art. 112, §5º da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.769/2019, corroborando o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há impedimento, portanto, para a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, ficando a cargo do Juiz das Execuções a especificação das entidades beneficiárias dos serviços e do valor fixado.

Por essas razões, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a expressão aritmética da pena privativa de liberdade e a substituição por restritivas de direitos, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR as rés FERNANDA DE LANA OLIVEIRA e MARIA BEATRIZ DE SOUZA SILVA como incursoas no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial aberto e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (23/03/2019) atualizado pela Tabela Prática do TJSP;

Com fundamento no art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena corporal das rés por 2 (duas) penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, ficando a cargo do Juiz das Execuções a especificação da entidade beneficiária dos serviços e do valor fixado.

Em razão do regime inicial fixado (aberto), primariedade e ausência de maus antecedentes, concedo o direito de recorrerem em liberdade.

Condeno as rés no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva;
- Intimem-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias;
- Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD).

P.I.C.

São Vicente, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA